

1500332-10.2021.8.26.0598
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/03/2022
... sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EM DECORRÊNCIA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADO.
[...] 4. Não se pode admitir que meras dificuldades financeiras justifiquem o cometimento do crime de tráfico de drogas, que tem por bem jurídico tutelado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500332-10.2021.8.26.0598
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254876/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20328432 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5306/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2254876 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
COSME SIMOES DE SALES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

COSME SIMÕES DE SALES e GIOVANE GASPAR DOS REIS estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal.

Notificados (fls. 245 e 247), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 255/260 e 271/276).

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 280/281) e os acusados foram citados (fls. 333 e 335).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 367 e 395/396).

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, nos termos da denúncia.

A defesa de Cosme pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e aplicação das benesses legais, e a de Giovane pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/11), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), fotografias (fls. 37, 39, 43 e 44), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 154/161 e 248/251) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, Giovane negou os fatos e aduziu que tinha acabado de parar na biqueira gerenciada por Cosme, a fim de adquirir maconha para seu próprio uso. Enquanto negociavam, os policiais chegaram e Cosme passou a caminhar para deixar o local, mas foram abordados. Não tinha droga em sua posse e não sabe informar se foi encontrado entorpecente com Cosme, porém o escutou discutindo com os policiais e dizendo que não tinha drogas e que não iria “segurar” o entorpecente. Os policiais ficaram irritados e afirmaram que prenderiam ambos. Teve envolvimento com o tráfico no passado, porém deixou essa atividade ilícita.

Cosme confessou a perpetração do delito e disse que somente vendeu drogas naquele dia, pois necessitava adquirir uma lata de leite para sua filha doente. Tinha em sua posse dez porções de cocaína e R\$ 800,00 em dinheiro. Esclareceu que vendeu maconha no passado, há cerca de oito anos, contudo agora só comercializava cocaína. Conhece Giovane de vista e não teve nenhum contato com ele antes da abordagem, inclusive porque o corréu estava do outro lado da rua quando os policiais chegaram. Admitiu a prática do comércio espúrio aos policiais e pediu que eles fossem à sua casa para comprovarem a situação de sua filha. Conhece o policial Caíque por terem estudado juntos e nada tem contra ele.

Os policiais militares Caíque e Aguinaldo relataram, em síntese, que receberam informações de populares de que dois homens morenos e magros, um deles vestindo uma bermuda de time de futebol, estavam traficando em um cruzamento. Foram ao local averiguar e se depararam com os réus, que, ao avistarem a viatura, demonstraram nervosismo, levantaram-se e tentaram sair dali caminhando. Abordados, em revista pessoal foram localizadas 10 porções de cocaína, celular e R\$ 1.135,00 com Giovane – que usava a bermuda de time de futebol –, e 12 porções da mesma droga e R\$ 787,00 com Cosme, todos esses valores em notas fracionadas. Não houve verificação do conteúdo do celular de Giovane naquele momento, tendo sido o aparelho entre à autoridade policial. Concretizaram buscas nas redondezas, porém nada mais de ilícito foi encontrado. Durante a diligência, os réus disseram que tinham sido previamente orientados por advogado de que deveriam declarar que as drogas teriam sido “entrujadas”.

A testemunha de defesa, Vitor, afirmou que Cosme passava por dificuldades financeiras por causa da doença da filha.

Ana Cristina disse que trabalhou com Cosme e não tem conhecimento sobre seu envolvimento com o tráfico.

Pedro, irmão de Giovane, disse que seu irmão teve problemas com drogas no passado, mas havia saído do meio escuso e estava trabalhando lícitamente como pintor.

Clonilson contou que Giovane lhe prestava serviço como pintor, com renda de R\$ 100,00 por dia. Efetuava o pagamento quinzenalmente, algumas vezes em dinheiro e

outras mediante transação bancária. Pagou Giovane no dia da prisão dele.

Pois bem.

Cosme admitiu a venda de cocaína no momento que foi abordado pelos policiais e sua confissão foi amparada pelo depoimento das testemunhas Caíque e Aguinaldo.

A alegação de problemas financeiros, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, mormente porque deveria ter buscado labor lícito para superar tais dificuldades. Ademais, Cosme alegou que somente vendeu drogas naquele dia para comprar uma lata de leite que custava aproximadamente R\$ 300,00, todavia ele tinha em seu poder mais do que o dobro de referida quantia.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EM DECORRÊNCIA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADO.

[...] 4. Não se pode admitir que meras dificuldades financeiras justifiquem o cometimento do crime de tráfico de drogas, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, e é de especial gravidade, tanto que equiparado a crime hediondo. 5. Recurso desprovido".

(TRF-3 - Ap: 00012228420084036181 SP, Relator: JUIZA CONVOCADA SILVIA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2011, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2011)

A tentativa dos acusados de escusar Giovane da responsabilização criminal restou frustrada diante do conjunto probatório.

Em juízo, Cosme negou ter conversado com Giovane antes da abordagem e disse que ele estava do outro lado da rua quando os policiais apareceram. Cosme afirmou, ainda, somente comercializar cocaína. Suas declarações são contraditórias com a narrativa de Giovane de que pretendia adquirir maconha e que estavam negociando com Cosme quando os policiais aportaram.

As versões conflitantes dos réus, a localização de cocaína tanto com Giovane quanto com Cosme e as denúncias de que um dos traficantes vestia uma bermuda de time de futebol – traje usado por Giovane na ocasião – corroboram a acusação descrita na denúncia.

Os policiais apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos e não foi suscitado qualquer motivo para que desejassem falsamente incriminar os acusados e não há qualquer razão para duvidar da palavra deles.

Nesse sentido, vale conferir:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Em arremate, ainda que o réu Giovane seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico, principalmente porque ele declarou ser consumidor de maconha, droga diversa à encontrada em sua posse. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO – Tráfico –

Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois a prática, pelos acusados, do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo as dosar as penas.

Na primeira fase, não verifico razões contundentes para majoração das penas-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para cada um dos réus.

Na segunda fase, observo pela certidão de fls. 235/236 que Giovane é reincidente específico (Processo nº 0006616-36.2015.8.26.0302). Para ambos, presente a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Portanto, majoro a reprimenda de Giovane de ¼ para 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa, e a de Cosme de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão em relação a Cosme, pois parcial e qualificada.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 a Giovane, em razão de sua reincidência. Cosme não também faz jus ao benefício, pois declarou que já ter vendido drogas anteriormente e foi apontado por Giovane como gerente de "biqueira", o que denota que se dedicava a esta atividade criminosa.

Fixo, para ambos, o regime inicial fechado para cumprimento de pena. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo, é a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias. Como esposado, Giovane é reincidente específico e Cosme exercia o comércio ilícito com assiduidade. A fixação de regime mais brando é, portanto, incompatível com a gravidade e reprovabilidade de suas condutas e não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, para ambos, pois ausentes elementos que demonstrem serem os réus capaz de arcar com valor maior.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a

ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do CPP poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado COSME SIMÕES DE SALES, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, e o réu GIOVANE GASPARD DOS REIS, com qualificação nos autos, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Os réus não poderão apelar em liberdade, pois permaneceram presos no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.3343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos com Cosme em favor da União.

Considerando o teor dos documentos juntados e o relato da testemunha Clonilson, não restou suficientemente demonstrado que a totalidade da quantia e o celular encontrados com Giovane tenham origem ilícita ou empregados no cometimento do crime. Assim, determino a oportuna restituição de tais bens, observando-se as cautelas de praxe.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA